

次の【見解】に関する後記アからオまでの各【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

横領罪の目的物は、犯人が占有する他人の物であり、物の給付者において民法上その返還を請求できるものであることを要しないので、不法な目的で金銭を委託した場合、委託者に返還請求権が認められなくても、受託者がこれを領得する行為には、横領罪が成立する。

【記 述】

ア. この【見解】に対しては、民法第708条にいう「給付」に「委託」は含まれないとする立場を前提としなければならず、妥当でないとの批判ができる。

イ. この【見解】は、用途を定めて委託された金銭の所有権は受託者に移転しないとする立場と明らかに矛盾するものである。

ウ. この【見解】に対しては、受託者が民法第708条に基づいて委託者からの返還請求を拒む行為にも横領罪が成立することになりかねず、妥当でないとの批判ができる。

エ. この【見解】は、横領罪の保護法益が所有権であることを重視し、委託信任関係の破壊という点を全く考慮していない。

オ. この【見解】に対しては、不法原因給付の目的物の所有権は、給付者において給付した物の返還を請求できないことの反射的效果として、受給者に帰属するに至ったと解すべきであるとする立場を前提とすると、横領罪にいう「他人の物」を領得したわけではないのに受託者に横領罪の成立を認めることになり、妥当でないとの批判ができる。

(参照条文) 民法

第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

ア 誤っている

【見解】は、民法上は他人の物にあたらないとしても、それに連動して刑法上も「他人の物」に当たらないとされるとは限らず、委託者の側に不法な領得行為に対して保護に値する利益を認めることができる以上、横領罪を認めることができるという立場に立っている。すなわち、【見解】は、「給付」に「委託」が含まれるかに拘わらず、いずれにせよ横領罪を肯定する見解である。よって、本記述は、【見解】に対する批判となっていない。

イ 誤っている

本記述のように、所有権は受託者に移転しないとするならば、所有権は委託者にとどまることになり、これを領得する行為は「他人の物」を横領することになるため、横領罪の成立を肯定することになる。よって、本記述によると【見解】と同様に横領罪の成立を肯定することになり、両者は明らかに矛盾するわけではない。

ウ 正しい

【見解】は不法原因給付物の領得行為に横領罪が成立することを肯定する説である。肯定説に対しては、否定説から、委託者の返還請求に対して受託者は返還を拒否して金銭を受領した以上、受託者に横領罪が成立するはずであるが、このような民法708条と正面から衝突する結論を採りうるかは疑わしいとの批判がなされている。

エ 誤っている

最大判昭45.10.21（民法百選Ⅱ73事件）によれば、民法708条は「みづから反社会的な行為をした者に対しては、その行為の結果の復旧を訴求することを許さない趣旨を規定したものと認められるから、給付者は、不当利得に基づく返還請求をすることも許されない筋合」であり、贈与者において給付物の返還請求ができなくなったときは、「その反射的效果として、目的物の所有権は贈与者の手を離れて受贈者に帰属するにいたつたものと解する」とされている。判例によれば、不法原因給付の場合、民法上所有権は相手方に移転するとされている以上、領得行為には所有権侵害がないはずなのに、本見解は横領罪の成立を認めているのであるから、むしろ、保護法益が所有権であることよりも、委託信任関係の破壊という点を重視しているといえる。

オ 正しい

所有権の帰属について、刑法上も民事判例である最大判昭45.10.21を尊重すべきだとすれば、所有権が移転しないことを前提にした横領罪肯定説はその論拠を失うことになる。よって、本記述は、同判例と同様の立場に立っており、【見解】に対する批判になっている。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。